

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4180/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย จัง กี หรือ จังกี แซ่เตี๋ย	โจทก์
	นาย ชุม พล ทอง แก้ว	จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 277, มาตรา 279

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 186 (7), มาตรา 214, มาตรา 215

ป.วิ.พ. มาตรา 147

จำเลยได้ถอดกางเกงในของตนออกแล้วจับผู้เสียหายซึ่งมีอายุไม่เกิน 13 ปี ถอดเสื้อกางเกง จากนั้นพาไปนอนหงายบนฟูก ของโจทก์ร่วม จำเลยนอนคว่ำทับ กอดจูบ ผู้เสียหายและได้พยายามเอาอวัยวะเพศของตนสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ ของผู้เสียหาย อันเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารและพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งอายุไม่เกิน 13 ปี การที่จำเลยได้กระทำอนาจารโดยถอดเสื้อผ้าจำเลยและผู้เสียหายแล้วนอนคว่ำทับ กอดจูบ ผู้เสียหายและได้พยายามกระทำชำเราผู้เสียหาย นั้น เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายที่จะกระทำชำเรา จึงเป็นความผิดกรรม เดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2778027991 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก 80279 วรรคสอง การกระ ทำความผิดดังกล่าวเป็นกรรมเดียว ให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา 279 วรรคสอง ดังนี้ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษายกฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก การที่โจทก์ไม่อุทธรณ์จึงไม่ถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจให้ศาลลงโทษ

จำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ความผิดฐานนี้ยังไม่ยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อจำเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277วรรคแรก และมาตรา 279 วรรคแรก มิใช่มาตรา 279 วรรคสองศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจปรับบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดคือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ให้ถูกต้องได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำอนาจารและพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ซึ่งอายุไม่เกิน 13 ปี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277, 80, 279, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายจังกี้หรือจังกี้บิดาผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 80, 279 วรรคสองการทำความผิดดังกล่าวเป็นกรรมเดียวให้ลงโทษบทหนัก ตามมาตรา279 วรรคสอง จำคุกจำเลย 6 ปี ให้ยกคำขอของโจทก์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 80, 279 วรรคแรกให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา 277 วรรคแรก, 80 กับให้ยกคำขอตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ด้วย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า รับฟังได้ว่าจำเลยได้ถอดกางเกงในของตนออกแล้วจับผู้เสียหายถอดเสื้อกางเกง จากนั้นพาไปนอนหงายบนฟูกของโจทก์ร่วม จำเลยนอนคว่ำทับกอดจูบผู้เสียหายและได้พยายามเอาอวัยวะเพศของตนสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย อันเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารและพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งมีอายุไม่เกิน 13 ปี การที่จำเลยได้กระทำอนาจารโดยถอดเสื้อผ้าจำเลยและผู้เสียหายแล้วนอนคว่ำทับกอดจูบผู้เสียหายและได้พยายามกระทำชำเราผู้เสียหายนั้นเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายที่จะกระทำชำเรา จึงเป็นความผิดกรรมเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง และฝ่ายโจทก์มิได้อุทธรณ์ถือว่าโจทก์ไม่พอใจให้ศาลลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ความผิดในฐานนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก จึงคลาดเคลื่อนนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษายกฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก แต่อย่างใด คงพิพากษาว่าความผิดดังกล่าวเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง อันเป็นบทหนัก เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าการ

กระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก และมาตรา 279 วรรคแรก มิใช่มาตรา 279 วรรคสองศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจปรับบทลงโทษจำเลยตามบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดคือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ให้ถูกต้องได้ความผิดฐานนี้หาได้ยุติไปแล้วดังที่จำเลยฎีกาไม่พิพากษายืน.

(กู่เกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>